

1501403-78.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... aos guardas a pratica de trafico no local. No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda Tiago, ouvido apenas na fase policial. O acusado, por sua vez, optou por tornar-se revel. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. A quantidade e a forma de apresentação das drogas revelam sua destinação para o tráfico, bem como a conduta do acusado ao tentar se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501403-78.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2270313/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 14431055 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3061/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2270313 - 02º D.P. PIRACICABA, 3061/20/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2270313/2020 - 07º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESTEVAO DOS SANTOS LOPES

Contr. nº 2020/001228

Aos 21 de julho de 2022, às 16:10 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Fernanda Guimarães Rolim Berreta foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Ausente o réu ESTEVÃO DOS SANTOS LOPES (intimado fl. 171). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GC TIAGO LUCAS DE LIMA e GC Glauco Ageu da Silva. Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Iniciados os trabalhos, diante da ausência do(s) réu(s), pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi determinado que se efetuasse pesquisa pelo sistema informatizado a fim de se verificar se o(a) acusado(a) encontra-se preso(a), o que foi feito, conforme documento que segue em apartado.

A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que, verificado que o(a) acusado(a) encontra-se egresso(a), DECRETAVA a REVELIA do(s) réu, com base no artigo 367 do

C.P.P..

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GM Glauco e GM Tiago) foram captados e gravados em áudio e vídeo. Dada a palavra a Dra. Promotora foi dito que desistia da oitiva(s) da(s) testemunha(s) GM Tiago, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ESTEVÃO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 18 horas e 3 minutos, na rua Paschoal Barsottini nº 255, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, ESTEVÃO trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 24 eppendorfs, contendo cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 34,6g; 8 invólucros plásticos, contendo cocaína em forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 8g; e 3 porções de maconha (Cannabis sativa L.), com peso bruto aproximado de 27,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 16/18). Apurou-se que guardas civis, em patrulhamento pelo local dos fatos, surpreenderam o acusado em atitude suspeita, eis que estava debruçado na janela de um veículo enquanto fornecia algo a seu condutor. Os guardas se aproximaram e, nesse momento, o veículo e acusado se evadiram. ESTEVÃO foi perseguido, abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrados, em sua mão, um eppendorf de cocaína e, em seu bolso, a quantia de R\$ 174,00 em dinheiro trocado, 23 eppendorfs de cocaína, 8 porções de crack e 2 porções de maconha. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 104, 116, 142 e 156/157. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/9, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos de constatação de fls. 16/18 e toxicológico de fls. 112/114. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. O Guarda Municipal Glauco narrou, em coesas declarações às prestadas na fase policial, que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o acusado debruçado na janela de um veículo. Ao se aproximar, o veículo deixou o local, e o acusado tentou fugir, mas foi detido na sequência. Realizada busca pessoal, foi encontrado em suas mãos uma porção de substância contendo cocaína e em seu bolso, foi localizado dinheiro em espécie, em notas trocadas, e 23 porções de substância aparentando ser cocaína, 8 porções aparentando ser crack e 2 porções de substância aparentando ser maconha. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que, ao ser indagado, o réu confessou informalmente aos guardas a prática de tráfico no local. No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda Tiago, ouvido apenas na fase policial. O acusado, por sua vez, optou por tornar-se revel. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. A quantidade e a forma de apresentação das drogas revelam sua destinação para o tráfico, bem como a conduta do acusado ao tentar se evadir da abordagem policial e a apreensão de certa quantia de dinheiro em notas trocadas em seu poder, juntamente com os entorpecentes. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que ESTEVÃO não possui antecedentes desabonadores (fls. 105/106). Na terceira fase, em que pese a primariedade, tem-se que o acusado apresenta diversas passagens pela Vara da Infância enquanto adolescente, bem como considerando a diversidade de entorpecentes apresentados, tem-se mostrar-se incabível a aplicação do redutor. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a) ESTEVÃO DOS SANTOS LOPES foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o

feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Na fase policial, por ocasião de seu interrogatório, o acusado ficou em silêncio. Em juízo, optou pela revelia, o que não pode ser considerado em seu prejuízo, já que poderia simplesmente ficar em silêncio, em legítimo exercício de direito constitucional expressamente previsto. Ainda durante a persecução penal foram ouvidos os dois guardas civis municipais, responsáveis por sua prisão, Glauco Ageu da Silve e Tiago Lucas de Lima. Na fase policial, os servidores municipais declararam que estavam em patrulhamento quando se depararam com o acusado debruçado sobre a janela de um veículo. Com a próxima da viatura, o condutor do veículo se evadiu e o réu também esboçou fuga, acabando, porém, detido. Realizada a busca pessoal, localizaram em sua mão uma porção de cocaína. Prosseguindo com as buscas, encontraram em seu bolso R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), vinte e três eppendorfs de cocaína, oito pedras de crack e duas porções de maconha. Judicialmente, tornaram a apresentar versão idêntica. Glauco afirmou que o local era ponto de tráfico e que o réu inicialmente confessou informalmente o tráfico, mas depois, na delegacia, passou a negar. Sobre o veículo, afirmou que se tratava de um modelo pequeno e de cor escura. Tiago também deu depoimento no mesmo sentido. Ou seja, como se nota, a prova é muito frágil, na medida em que só foram ouvidos os responsáveis pela sua prisão que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos guardas municipais estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7ª Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): "Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes de segurança, nenhuma outra prova foi produzida. Na verdade, observa-se que os guardas relataram que o réu mantinha contato com o condutor do veículo, mas nenhum esforço fizeram para identificar essa pessoa para melhor esclarecimento dos fatos. Pelo que se observa ainda, os fatos se deram na via pública, mas não foram

ouvidas testemunhas civis que indicassem que o réu estivesse realmente traficando. Ou seja, era possível a produção de outros tipos de prova, porém, por aqui, há apenas o que disseram os guardas municipais, o que constitui prova muito precária, ainda mais em se tratando de grave crime. Não se quer dizer que os policiais mentiram, mas apenas que, para a condenação, prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Dessa forma, por tudo que foi exposto, sendo frágil o conjunto probatório, a Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caso de condenação, requer-se seja fixada a pena no mínimo legal. Na terceira fase de aplicação, de rigor a diminuição da pena em decorrência da incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que todos os seus requisitos se mostram presentes. Trata-se de acusado primário, que, em tese, estava em poder de pequena quantidade de entorpecente. Nenhuma prova de que integra organização ou associação criminosa. O que ele ostenta são registros pela prática de atos infracionais mais graves, os quais, porém, remetem aos anos de 2014 e 2016. Logo, há uma distância temporal considerável entre essas ocorrências pretéritas e o fato que é objeto da presente ação penal, ocorrido em outubro de 2020. Sobre isso impende destacar que no âmbito da 3ª Seção do C. STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 08/09/2021, prevaleceu o "entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração". Assim, esses dados não podem ser considerados em desfavor do acusado, que deve ter sua pena diminuída, autorizando-se, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal em caso de conversão. Caso, no entanto, não se aplique a causa redutora de pena, pugna-se para que, ao menos, seja fixado o regime semiaberto, compatível com a primariedade do acusado. Por fim, ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, requer-se que seja autorizado que o réu apele em liberdade, caso assim deseje.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

ESTEVÃO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 18 horas e 3 minutos, na Rua Paschoal Barsottini nº 255, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 24 "ependorfs", contendo cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 34,6g; 8 invólucros plásticos, contendo cocaína em forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 8g. e 3 porções de maconha (Cannabis sativa L.), com peso bruto aproximado de 27,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 16/18).

Narra a denúncia que guardas civis, em patrulhamento pelo local dos fatos, surpreenderam o acusado em atitude suspeita, isto é, debruçado na janela de um veículo enquanto fornecia algo a seu condutor. Os guardas se aproximaram e, nesse momento, o veículo e o réu se evadiram.

O acusado foi perseguido, abordado e submetido à busca pessoal. Da providência se verificou que o ele trazia consigo, na mão, um "ependorf" de cocaína. No bolso havia R\$ 174,00 em dinheiro trocado, 23 "ependorfs" de cocaína, 8 porções de crack e 2 porções de maconha.

Conclui a denúncia que a quantidade e variedade de drogas evidenciam sua destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 116). Defesa preliminar apresentada às fls. 119/120. Após, a denúncia foi recebida (fls. 142) e

o réu foi citado (fls. 155).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado, pois revel.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

1) Boletim de ocorrência de fls. 08/10;

2) Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e fotografia de fls. 13;

3) Laudo de constatação preliminar de fls. 16/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 112/114, ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu permaneceu silente.

Em juízo também não exerceu a autodefesa, tornando-se revel.

Ouvido na fase informativa (fls. 03) e em juízo (gravação), o guarda municipal Glauco Ageu da Silva declarou que estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Oriente, e, ao entrarem na Rua Monsenhor Bastos, em local conhecido como ponto de tráfico, viram um veículo parado no centro da via e um indivíduo debruçado na janela do motorista entregando algo ao condutor, em atitude típica de tráfico de drogas. Ao se aproximarem o veículo, seu condutor saiu rapidamente sem ser identificado e o acusado também tentou se evadir, saindo rapidamente do local, mas foi detido. Com ele, em sua mão, encontraram uma porção de cocaína, e em seu bolso, dinheiro em espécie em notas diversas, 23 porções de cocaína, 08 de "crack" e 02 de maconha. Disse que, informalmente, o réu admitiu o tráfico, mas, perante a Autoridade Policial, negou o crime. Por fim, afirmou que não o conhecia anteriormente.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) pelo guarda municipal Tiago Lucas de Lima, o qual divergiu de seu colega apenas ao afirmar que, indagado sobre as drogas, o réu alegou ser usuário.

Anoto que os relatos dos guardas municipais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Não há indícios de que tenham mentido em seus depoimentos ou que tenha havido quebra da incomunicabilidade, até mesmo porque houve pequena divergência entre seus relatos (o primeiro afirmou que, informalmente, o réu confessou o tráfico, ao passo que o segundo declarou que o réu apenas disse ser usuário). Se tivessem se comunicado entre os depoimentos de um de outro (o que também não se mostrou viável em razão do ínfimo lapso temporal entre a saída do primeiro depoente da audiência e o ingresso do segundo), certamente não teriam incidido na contradição apontada.

No mais, presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,

sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Registro que os relatos dos agentes não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 24 "eppendorfs" contendo cocaína, 8 invólucros contendo "crack" e 3 porções de maconha, substâncias estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, os guardas foram uníssonos e convergentes em seus depoimentos no sentido de que surpreenderam o réu debruçado na janela de um veículo, entregando algo para seu condutor, ou seja, em situação absolutamente comprometedor e indicativa do tráfico de drogas. Ademais, ao notar a presença da viatura, o condutor do automóvel empreendeu deixou rapidamente o local e o réu, apesar de também ter tentado se distanciar dali, foi contido e, com ele, foram encontradas diversas porções de entorpecentes e quantia de dinheiro em notas trocadas (R\$174,00), cuja origem

lícita não foi comprovada e, evidentemente, foi obtida com as vendas ilícitas, tudo a confirmar a traficância.

O destino mercantil se reforça com a quantidade expressiva de entorpecentes e sua variedade, incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a isso o fato de as drogas estarem embaladas em porções individuais, da forma como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 13).

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A existência de diversidade de drogas e a quantidade, embora mais expressivas a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de diminuir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal. Inexistem causas de aumento.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui passagens na Vara da Infância e Juventude com condenações por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas (autos nº 13916-24.2014, fls. 139/140 c.c. fls. 132/133 em que lhe foi aplicada a medida de liberdade assistida e nº 11371-10.2016, fls. 134/137 c.c. fls. 126/127, com aplicação da medida socioeducativa de internação, a qual foi extinta quando atingiu a maioridade), o que demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas, notadamente o tráfico de entorpecentes, atividade que vem fazendo como meio de vida.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou traficando.

Tratando-se, portanto, de traficante que vem reiterando nas atividades criminosas, não se pode equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas desde a adolescência, não comprovando atividade lícita, e agora portando e mantendo em sua guarda expressiva quantidade de entorpecente para fins de tráfico.

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVACÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitiva, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas

colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 10. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração das majorantes para 1/6, ficando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. PASSAGENS ENQUANTO MENOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA TOTAL SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pelo fato do paciente ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. In casu, resta evidenciado o constrangimento ilegal na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, a fixação foi em razão da hediondez e da gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior, mormente se considerarmos que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (uma porção de maconha com peso de 39,16g). Dessa forma, considerando, ainda, que o paciente é

primário, bem como o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias superior a 4 anos, o pleito quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena do paciente". (HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram, fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso com considerável quantidade de cocaína - 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4. Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito anos (Súmula nº 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida". (HC 212.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j. em 15/09/2011).

Incabível, assim, o privilégio.

Quanto ao regime de pena, rendendo-me ao posicionamento das duas Turmas do C. STJ, conforme julgados supracitados, deixo de fixar o fechado, para eleger o semiaberto, eis que a quantidade de drogas, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância. No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha reiterando nas atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Ademais, o crime de tráfico de drogas tem graves consequências, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Necessária, assim, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos, as quais também são incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada. Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio. Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas dos réus.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ESTEVÃO DOS SANTOS LOPES a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pela DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestariam sobre sentença ora proferida no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos.

Intime-se o(a) ré(u) do teor da sentença, bem como se dela deseja recorrer. Com a juntada do mandado, devidamente cumprido, dê-se vista à Defensoria Pública para eventual interposição de recurso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.